

1502363-47.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... do entorpecente, porém negou o delito de tráfico de drogas, alegando que é usuário de drogas e às pedras de de crack eram para consumo próprio.

No entanto, os policiais militares Nilson e Daniel foram unânimes em afirmar que em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado Isaías em atitude suspeita, sendo que este ap ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502363-47.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502363-47.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2271967/2020 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 14464600 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

10631/20/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2271967 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

3, 10631/20/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou ISAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES como incurso no art. 33 caput da Lei n. 11.343/06, conjugados aos arts. 40, inciso III e art. 61, inciso II, alínea 'j' (calamidade pública) do Código Penal, pelos fatos a seguir narrados.

No dia 3 de novembro de 2020, por volta das 19h00, na rua Santos Dumont, nº 10, bairro Vila Tibério, próximo à Unidade Básica Distrital de Saúde Central Dr. João Baptista Quartin, nesta cidade e comarca, ISAIAS, durante o período de calamidade

pública ocasionado pelo novo corona vírus, após adquirir de maneira escusa, guardava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros a quantia de 3,750 g (três gramas e setecentos e cinquenta miligramas) de substância sólida de cor parda, acondicionados em 53 (cinquenta e três) invólucros de plástico, contendo substância conhecida como "crack" sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades da rua Santos Dumont, quando avistaram ISAIAS em atitude suspeita, situação em que decidiram efetuar a abordagem do ora acusado.

Durante revista pessoal, os agentes encontraram na mão direita do réu 53 pedras de "crack" embaladas e prontas para serem comercializadas, e no bolso de sua bermuda R\$ 50,00 em notas diversas.

Com efeito, a destinação da droga ao comércio ilícito restou evidenciada por sua considerável quantidade, forma de divisão e acondicionamento, além das circunstâncias em que o acusado foi encontrado pelos agentes públicos, restando evidente características da narcotraficância.

Em 21 de julho de 2021 foram declarados suspensos o processo e o prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 121/122). O réu foi pessoalmente citado (fls. 159), razão pela qual, em 06 de outubro de 2021 foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional e determinado regular prosseguimento do feito (fls. 154). O acusado ofereceu resposta à acusação, arrolando as mesmas testemunhas constantes na denúncia e mais uma testemunha de defesa (fls. 163/168). A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 174/176).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da ação penal para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. Postulou aplicação da pena acima do mínimo legal, um vez que o acusado ostenta uma distribuição pelo delito de roubo. O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado, sendo-lhe vedado quaisquer benefício.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito imputado ao réu, para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Em caso de outro entendimento, aplicação da pena-base no mínimo legal; que a agravante prevista no artigo 40, inciso III, da lei de drogas e a majorante da calamidade sejam afastadas e a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º da lei de drogas, em grau máximo. Por fim, requereu regime inicial de cumprimento da pena aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Este é, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade restou amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10), pelo laudo de constatação provisória (fls. 11/13), pela imagem (fls.19), pelo croqui (fls.74), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo, que concluiu que o material submetido continha METIL BENZOIL ECGONINA

(COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca" (fls. 77/78) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O acusado negou o delito que lhe foi imputado na denuncia, alegando que é usuário de entorpecente e que às pedras que crack que portava eram destinadas ao próprio consumo. Esclareceu que somente parte do entorpecente lhe pertencia, que é morador de rua e que usou o dinheiro do auxílio do governo para adquirir o entorpecente. Negou a propriedade do dinheiro apreendido.

A testemunha Nilson Rodrigues Pinto, policial militar, informou que durante patrulhamento pelo local dos fatos, o acusado foi visto em atitude suspeita, em local conhecido como "ponto de venda de drogas", esclarecendo que este ao perceber aproximação policial assustou-se e tentou sair do local, razão pela qual foi abordado. Durante revista pessoal foram localizadas em seu poder 53 pedras de crack, embaladas individualmente e em tamanhos iguais, prontas para serem comercializadas, bem como a quantia de cinquenta reais em notas de pequeno valor. O acusado vestia roupas características de morador de rua. Indagado, o réu alegou que era usuário e a droga seria para seu consumo. Já tinha abordado o acusado outras vezes. Não se recorda se foram abordada outras pessoas na data dos fatos, tendo em vista o tempo decorrido. O dinheiro e a droga estavam no bolso da bermuda. Não viu o réu conversando com outras pessoas.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Daniel Napoleão de Oliveira, policial militar, asseverando que durante patrulhamento pelo local dos fatos, sendo que quando o acusado percebeu a aproximação policial se assustou e tentou sair do local, razão pela qual foi abordado. Esclareceu que o local é conhecido como "ponto de venda de drogas". Em busca pessoas foram localizadas em poder do acusado 53 pedras de crack, embaladas individualmente e em tamanhos iguais, prontas para serem comercializadas, bem como a quantia de cinquenta reais em notas de pequeno valor. Indagado, o réu alegou que era usuário e a droga seria para seu consumo.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia. Senão vejamos.

O acusado admitiu a posse e a propriedade do entorpecente, porém negou o delito de tráfico de drogas, alegando que é usuário de drogas e às pedras de crack eram para consumo próprio.

No entanto, os policiais militares Nilson e Daniel foram unânimes em afirmar que em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado Isaias em atitude suspeita, sendo que este ao perceber a aproximação policial se assustou, razão pela qual optaram pela abordagem. Em revista pessoal, no bolso da bermuda do réu, foram localizadas 53 pedras de crack, todas do mesmo tamanho, embaladas individualmente. Indagado informalmente, o acusado alegou que o entorpecente seria para consumo próprio.

Do exposto, evidente que a negativa do acusado não o socorre. Isso porque os relatos de ambos os milicianos revelaram-se críveis, coesos e insuspeitos, até porque deixaram evidente que a abordagem do réu se deu pela sua atitude, em local de intensa traficância, sendo que este ao visualizar a equipe policial assustou-se e tentou sair do local.

Não convence a narrativa do réu que somente parte do entorpecente lhe pertencia e que não portava dinheiro no momento da abordagem. Cremos que sem sombra de dúvida que a verdade esta na palavra dos policiais Nilson e Daniel, uma vez que nenhuma prova foi trazida aos autos no sentido de que os milicianos tivessem a intenção de prejudicar o réu, atribuindo-lhe valor em dinheiro e quantidade de entorpecente superior a que ele trazia consigo. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi

trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos milicianos.

Assim, a narrativa dos milicianos merece crédito, com citações oportunas das ementas que seguem

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade - Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal”. (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCO DE GODOI - CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94);

Da mesma maneira, é o posicionamento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: “os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em juízo, constituem-se prova idônea à condenação” (STJ, 6ª Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

O fato de não ter o acusado sido surpreendido comercializando o entorpecente não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. A figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos “(...) trazer consigo, ter em depósito (...) guardar (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, o que ficou sobejamente demonstrado. Portanto, deve o réu ser responsabilizado pelo disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja conduta típica ficou devidamente caracterizada.

Sabe-se, que somente a assertiva de ser dependente químico, não enseja a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/06, até porque, não há qualquer incompatibilidade entre a condição de usuário de drogas e o tráfico, sendo usual a figura do viciado traficante que utiliza os rendimentos do comércio ilícito, justamente para sustentar o próprio vício. Nesse sentido: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – rel. Onei Raphael – RTJSP 101/498). No mesmo sentido: RT 837/595 (TJSP – ap. 1468651/0-00 – 14ª Câmara – j. 31/03/2005, rel. Wilson Barreira) e RT 841/533 (TJSP – ap. 494.181-3/5-00 – 5ª Câmara – j. 28/07/2005 – rel. Des. Pinheiro Franco).

A quantidade de droga apreendida, embalada de forma individual, pronta para a imediata comercialização, bem como a apreensão de dinheiro, deixa fora de dúvida que os entorpecentes seriam destinados ao nefasto comércio.

Afasto a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, um vez que não restou devidamente comprovado que a destinação das drogas apreendidas com o réu seria para os frequentadores da Unidade Básica de Saúde (UBDS) “Dr. João Baptista Quartin”. Ademais, os milicianos no momento da abordagem não presenciaram o acusado comercializando o entorpecente.

Afasto a agravante prevista na alínea 'j', inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que não restou comprovado nos autos que o acusado tenha se aproveitado das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade Pública causada pela pandemia do COVID-19.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ainda na segunda fase, a i.Magistrada reconheceu a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal - crime cometido durante período de calamidade pública. Naquela oportunidade, exasperou a pena em 1/6. A operação comporta reparos. Isso porque não há provas de que o estado de emergência sanitária tenha de alguma forma facilitado a prática delituosa. Não há provas de que o acusado tenha se aproveitado daquela situação. A agravante não incide apenas pela existência do estado de emergência". (Apelação Criminal nº 1500709-27.2020.8.26.0594 - Voto nº 2253 - Relator: MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILI).

"Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19. Assim, não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente, de rigor o afastamento da agravante em questão, mantendo-se inalterada a reprimenda" (Apelação Criminal nº 1512067-20.2020.8.26.0228 - Voto nº 12.641 - Relator: ANDRADE SAMPAIO).

Destarte, demonstrada a autoria e materialidade a condenação é medida de rigor.

Colocadas tais ponderações, passo a fixar a pena do réu.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, nos termos do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. A pena-base foi fixada no mínimo legal, por entender que não é possível considerar ações penais e inquéritos policiais em andamento para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do acusado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL- HOMICÍDIO QUALIFICADO-CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI-AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS-RECURSO DA DEFESA-INCONFORMISMO QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA-VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE-CONDENAÇÃO POSTEIRO AO FATOS-IMPOSSIBILIDADE-REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL-APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na primeira fase da individualização da pena, o magistrado deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de Discricionariedade, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição federal, motivando quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito porquanto, a princípio, é de bom alvitre que a personalidade seja avaliada em laudo profissional. Inquéritos policial, ações penais em curso e sentenças condenatórias com trânsito em julgado providas de fatos posteriores ao que se examina não podem ser utilizados para macular a personalidade do agente, onal apto a traça-la. (TJ-MT-APL 00028898920108110002 MT, Relator. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. Data de Publicação:28/08/2017). Grifo Meu.

Deixo de reconhecer a confissão do acusado, uma vez que ele confessou o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas e não o delito que lhe foi imputado na denuncia.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Tendo em vista que o réu é tecnicamente primário e a sua não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno as penas acima definitivas.

Em decorrência da modificação do artigo 44 do Código Penal pela Lei nº 9.714/98, vislumbrando que a pena aplicada ao réu é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido mediante violência e o réu é tecnicamente primário, bem como os demais requisitos previstos no inciso III do referido artigo indicam seja a substituição suficiente, promovo-a.

Em consequência, e observando-se o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à acusado por duas penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da condenação, em instituição a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, e a outra o pagamento de multa, no valor de dez (10) dias-multa, a serem somados aos cento e sessenta e seis (166) dias-multa da sanção originária e revertidos ao Fundo Penitenciário Nacional.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, considerando-se a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais, sendo suficiente para fins de prevenção e repressão criminais.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ISAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, RG nº: 63.374.487 e o CONDENO com fundamento no artigo 33 caput da Lei n. 11.343/06, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão - substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma consistente em prestação de serviços à comunidade e a outra pagamento de multa, no valor 10 (dez) dias-multa, e o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Nos termos da lei 12.736/12, o tempo em que o acusado permaneceu recluso, a título de prisão provisória e em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e tudo mais que for necessário para o cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução penal, tendo em vista ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA